

1000148-95.2017.8.26.0584

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes contra a Ordem Tributária

Magistrado: Luis Carlos Martins

Comarca: São Pedro

Foro: Foro de São Pedro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... jurisprudência:

"APELAÇÃO. DEFESA. Tráfico ilícito de entorpecentes e resistência. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 e 329, do Código Penal. Sentença de procedência.

Preliminares rejeitadas. Ingresso de policiais no domicílio do acusado que se deu após constatada situação de flagrante delito, caracterizando justa causa para a realização da busca e apreensão a despeito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro

Foro de São Pedro

1ª Vara

PRAÇA ADOLPHO BONIFÁCIO BRAGAIA, S/N, São Pedro - SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000148-95.2017.8.26.0584 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000148-95.2017.8.26.0584 - Controle nº 2017/000068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes contra a Ordem Tributária

Autor:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Réu:

Regina Marcia Baptistella de Godoy e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Carlos Martins

I - RELATÓRIO

Vistos,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de investigação do núcleo de autuação integrada de combate aos crimes de sonegação fiscal (Expediente MP n. 165/2016-SONF) de fls. 7/89, ofereceu denúncia contra REGINA MARCIA BAPTISTELLA DE GODOY e BENEDITO ADALBERTO DE GODOY tendo-os por incurso no artigo 2º, II, c.c. o artigo 11, caput, c.c. o artigo 12, inciso I, todos da Lei n. 8.137/90, c.c. o artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, imputando-lhes os seguintes fatos: "nos meses de janeiro, fevereiro, março, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014 e de janeiro, fevereiro e março de 2015, na empresa Godoy & Baptistella Industria e Comercio de Produtos de Higiene LTDA, localizada na Estrada da Boa Vista, s/n, Chácara Boa Esperança, na cidade de Santa Maria da Serra, nesta Comarca, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, na condição de sócios e

administradores da empresa mencionada, por 10 vezes e de modo continuado, deixaram de recolher, no prazo legal, valor de ICMS total de R\$1.980.191,84 cobrado do substituído na qualidade de substituto tributário e que deveria recolher aos cofres públicos do Estado de São Paulo, ocasionando grave dano à coletividade.

A exordial peça acusatória ofertou, ainda, denúncia contra ANA CLELIA DE GODOY e BENEDITO ADALBERTO DE GODOY, tendo-os como incursos no artigo 2º, II, c.c. o artigo 11, caput, c.c. o artigo 12, inciso I, todos da Lei n. 8.137/90, c.c. o artigo 29 do Código Penal, imputando-lhes os seguintes fatos: “no mês de junho de 2015, também na empresa Godoy & Baptistella Industria e Comercio de Produtos de Higiene LTDA, previamente ajustados e com unidade de desígnios, na condição de sócios e administradores da empresa mencionada, deixaram de recolher, no prazo legal, valor de ICMS total de R\$ 74.602,64 cobrado do substituído na qualidade de substituto tributário e que deveria recolher aos cofres públicos do Estado de São Paulo, ocasionando grave dano à coletividade.

A denúncia foi recebida em 20/02/2017 (fls. 90).

Os réus foram devidamente citados (fls. 183/184, 189, 190).

O Ministério Público em audiência realizada no dia 02/04/2018, ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, que não foi aceita pelos réus e seu defensor.

O defensor constituído apresentou resposta à acusação (fls. 196/198).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária (fls. 199/200), foi designada audiência, na qual foram ouvidas testemunhas, com eventual interrogatório dos réus. Em memoriais finais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu Benedito Adalberto de Godoy, pugnando por sua condenação nos termos da peça acusatória e discorreu sobre a dosimetria da pena. Quanto às rés Regina Márcia Baptistella de Godoy e Ana Clélia de Godoy, o Ministério Público pugnou pela absolvição ante à falta de provas suficientes para a condenação (fls. 513/525).

Por sua vez, em seus memoriais, os réus alegaram matéria preliminar ao mérito consistente em inépcia da denúncia, impossibilidade de reparação do dano e nulidade da instrução processual. Ao adentrar o mérito pleitearam a absolvição, sustentando que não há nos autos prova do dolo de sonegação fiscal, mas mera inadimplência.

Alega que houve declaração tributária com escrituração dos débitos e créditos de todas as operações realizadas com emissão dos documentos fiscais necessários. Portanto, segundo alega, não houve dolo de crime com a ordem tributária, mas mera inadimplência em vista de falha interna da empresa e dificuldades financeiras enfrentadas. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena e fixação da pena no mínimo legal (fls. 180/181).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de inépcia da denúncia, posto que a inicial acusatória preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal ao descrever as circunstâncias do fato criminoso e as condutas dos agentes, não havendo se falar em denúncia genérica, tanto que foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa com o oferecimento da resposta à acusação.

Afasta-se, outrossim, a alegada nulidade processual em vista da inversão da ordem de inquirição das testemunhas e interrogatório (CPP, art. 400), posto que é disposição expressa do artigo 563, do Código de Processo Penal que nenhum ato será declarado nulo caso não haja prejuízo à defesa (pas nullité sans grief).

E na hipótese dos autos não se vislumbra prejuízo à defesa, pois presentes os acusados na audiência de fls. 342 em que determinado se aguardar a oitiva da testemunha a ser ouvida por carta precatória sem que se opusessem à prática do ato após o interrogatório, o que faz vislumbrar a concordância e, portanto, que não haveria prejuízo à defesa.

Além disso, insuficiente a alegação genérica para se afastar a aplicação de suprimimento de nulidade prevista no artigo 563, do Código de Processo Penal em vista da inversão da ordem, mas deve haver indicação precisa do prejuízo experimentado pela defesa e, na hipótese dos autos, nota-se que a testemunha Reginaldo, ouvida após os acusados, foi arrolada somente pela defesa e não trouxe qualquer fato novo que pudesse piorar a situação dos acusados.

Por fim, restou preclusa a alegação da nulidade, pois deduzida somente em sede de

memoriais de defesa e mesmo intimados da ordem da oitiva nas audiências de fls. 342 e 501/502 nada se opuseram, logo, vedado no sistema de processual penal a denominada nulidade da algibeira uma vez que viola a boa-fé, segundo entendimento consolidado na jurisprudência:

"APELAÇÃO. DEFESA. Tráfico ilícito de entorpecentes e resistência. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 e 329, do Código Penal. Sentença de procedência. Preliminares rejeitadas. Ingresso de policiais no domicílio do acusado que se deu após constatada situação de flagrante delito, caracterizando justa causa para a realização da busca e apreensão a despeito de desprovida de autorização judicial ou consentimento. Ausência de violação à jurisprudência dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Alegação de violação à cadeia de custódia da prova que, além de atingida pela preclusão, não restou comprovada nos autos. Sistema processual penal que não admite a nulidade de algibeira. Prejuízo, ademais, não demonstrado. Inteligência do artigo 563, do Código de Processo Penal. Interrogatório do réu como primeiro ato da instrução processual. Nulidade não verificada. Rito especial da Lei de Drogas. Jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores. Mérito. Pretensão absolutória acolhida quanto ao tráfico de drogas. Indícios insuficientes para a prolação de um decreto condenatório. Dúvida que se resolve em favor do acusado. Aplicação do brocardo in dubio pro reo. Condenação bem lançada quanto ao crime de resistência. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Testemunhos firmes e coerentes, deles não se extraíndo mendacidade ou motivação menos legítima de incriminar falsamente o sentenciado. Dosimetria. Correto o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência. Alteração apenas da expressão aritmética constante do dispositivo da r. sentença, que não reflete a individualização retratada na fundamentação do decisor. Regime inicial alterado para o aberto com base no princípio da proporcionalidade, que atende às finalidades preventiva e retributiva da pena. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJ-SP. Ap n. 1500062-58.2019.8.26.0435. Rel. Des. Camargo Aranha Filho. J. 24.7.2022 - destaque próprio).

Por fim, no que tange a oposição quanto à proposta de suspensão processual, veja-se que as partes expressamente recusaram os termos do acordo, cuja reparação do dano é exigência legal para concessão da suspensão processual prevista no artigo 89, § 1º, I, da Lei 9.099/95, logo, não há ilegalidade na exigência.

Além do que, trata-se de matéria preclusa nos autos, pois transitada em julgada nos autos de Habeas Corpus de fls. 447/455.

No mais, processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos contra a ordem tributária descritos na denúncia foi demonstrada nos autos pelo relatório de apuração do ICMS (fls. 10/20), certidões de dívida ativa (fls. 21/31), bem como prova oral colhida em Juízo.

A autoria é certa e deve ser imputada aos réus. Senão vejamos.

O informante do juízo Gabriel Baptistella Peres, em juízo relatou que é sobrinho da ré Regina e que trabalha no setor financeiro da empresa. Esclareceu que a partir do ano de 2013 a empresa enfrentava uma grande dificuldade financeira, sendo solicitado recuperação judicial no de 2015, pois a situação havia piorado. Relatou que nessa época houveram muitas demissões de funcionários e afirmou que diversos tributos não foram recolhidos, pois tentaram preservar a operação da empresa, que possuía mais de 400 funcionários. Contou que em 2014 e 2015 tiveram muitas demissões. Confirma que o ICMS não foi recolhido para preservação da operação da empresa, bem como se priorizou os pagamentos das verbas trabalhistas. Afirmou que as operações da transportadora acontecem na cidade de Jundiaí. Esclareceu que Regina não frequentava a empresa e que cedeu sua participação na sociedade para Ana Clélia, que participava apenas da parte de Recursos Humanos na transportadora de Jundiaí. Aduz que toda a administração era realizada por Adalberto. Contou que a partir de 2011 começou uma profissionalização na empresa, tendo um diretor para

cada setor e que as decisões da empresa eram tomadas pelos diretores. Nega que a Regina participava das atividades da empresa e a Ana Clélia participava somente das decisões relacionadas ao setor de Recursos Humanos. Acrescenta que entre final de 2014 a início de 2015 a empresa perdeu cerca de 90% do seu faturamento. Disse que nas demissões ocorridas no ano de 2014 houve o pagamento parcelado das verbas rescisórias, sem a multa, e que no ano seguinte, quando ocorreu mais demissões, as verbas rescisórias não foram pagas. Afirmou que muitos funcionários entraram com ação trabalhista. Confirma que é cobrado o ICMS na nota fiscal (mídia de fls. 509). A testemunha Rodrigo Zerbini Araújo, em juízo (carta precatória) declarou que foi funcionário da empresa objeto dos autos de 2006 até o ano de 2015. Afirmou que a ré Ana Clélia de Godoy era responsável pelo setor de recursos humanos e que Regina, a esposa de Benedito Adalberto, participava pouco da gestão. Aduz que Adalberto era o gestor principal. Afirmo que a empresa tinha cerca de 300 funcionários e o Município de Santa Maria da Serra com cerca de 5000 habitantes dependia diretamente da movimentação econômica desenvolvida pela empresa inclusive quanto à movimentação turística. Esclareceu que a empresa enfrentou uma grande crise financeira, havendo dificuldade para pagar todas as despesas, gerando uma recuperação judicial. Aduz que falta de liquidez de contratos com o setor público contribuíram para aprofundamento da crise financeira. Afirmou que nessa época eram priorizadas as despesas principais, como folha de pagamento, compra de matéria-prima, energia elétrica e contratos de banco, recordando-se que de fato alguns impostos não foram pagos por falta de recursos. Conta que a empresa fez débitos de curto prazo para investimentos de longo prazo. Houve demissão grande de funcionários. Relatou que o réu Benedito Adalberto vendeu bens pessoais para tentar adimplir com as dívidas. Não sabe se foram efetivados pedidos de parcelamento, mas sabe que havia intenção de realizar o parcelamento do débito (mídia de fls. 509).

A testemunha Wellington Jon Holland, em juízo (carta precatória - fls. 323 e mídia de fls. 509) disse que a ré Regina não participava da gestão da empresa e não era responsável por nada. Esclareceu que a empresa entrou em recuperação judicial e demitiu por volta de 300 funcionários. Além disso, afirmou que a economia da cidade de Santa Maria da Serra dependia muito da empresa. Acrescenta que a empresa continuou a pagar os salários dos funcionários para evitar clamor social na porta de sua casa em vista da empresa estar sediada em cidade pequena.

A testemunha Edilson Gama Barbosa Cintra, em juízo (carta precatória - fls. 257) contou que trabalhou na empresa Godoy & Baptistella Industria e Comércio de Produtos de Higiene LTDA., na parte de compras há 14 anos. Contou que desconhece informações sobre a parte tributária, apenas sabe acerca do funcionamento da empresa, a qual após grande crescimento entrou em uma severa crise dispensando muitos funcionários. Confirmou que o período referido no processo era exatamente quando o proprietário criou parcerias deixando a gestão da empresa à terceiros, os quais fizeram maus negócios levando a empresa à crise. Relata que a parte contábil da empresa era terceirizada, apenas tem conhecimento que por haver diversas filiais em cada uma havia um setor de contabilidade com alguém responsável, não sendo algo unificado. Disse que somente o sr. Benedito Godoy administrava a empresa, a sra. Regina sua esposa não tinha participação e a sra. Ana Clélia apenas geria os recursos humanos da referida, aduziu que apesar do sr. Benedito responder pelas decisões havia outras parcerias.

A testemunha Alex Gama Salvaia, em juízo (carta precatória - fls. 322) declarou conhecer a empresa desde 2013, a qual enfrenta uma situação financeira grave entrando em recuperação judicial em maio de 2015 com cerca de 300 credores. Relata ter assumido o jurídico da empresa a partir de maio de 2016, atualmente está sendo pago os credores trabalhistas e em agosto inicia o pagamento dos credores quirografários. Conta que a crise iniciou devido ao prejuízo pela empresa ter entrado no mercado de marcas licenciadas e ter diminuído seu volume de vendas. Reafirma que em maio de 2015 a empresa entrou em recuperação judicial não efetuando pagamentos pontuais desde o tributo até os fornecedores. Foram feitos acordos com o INSS e o Ministério Público a fim de regularização. Disse que na prática o administrador era apenas o Sr. Benedito, que a família comprometeu patrimônio pessoal para adimplir os débitos antes mesmo da execução fiscal sendo em 2015

oferecido bens imóveis à Fazenda. Acerca dos funcionários contou ter havido em cerca de 450 no auge, durante a crise cerca de 60 e atualmente 150 funcionários, houve mais de 250 ações trabalhistas contra a empresa sendo boa parte já liquidada. A testemunha Reinaldo Mizumoto, em juízo disse que era vendedor na empresa e que mantinha contato com o senhor Benedito. Afirmou que poucas vezes no local a senhora Regina. Aduz que via na empresa somente o senhor Benedito realizar atos de administração. Soube que os réus eram pessoas honestas e não sabe de nada que os desabone. Sabe que a empresa entrou em Recuperação Judicial. Alega que "trabalhava na rua", bem como que somente se reportava por e-mail. Foi cerca de 15 vezes na empresa e que nas vezes que foi viu o senhor Benedito. Nega saber de sonegação e não tinha relacionamento pessoal com os acusados não sabendo se tinham vida abastada (mídia digital de fls. 500).

Em juízo a ré Regina Marcia Baptistela de Godoy declarou que não participava da movimentação da empresa e que não tinha conhecimento sobre os fatos tampouco sobre as participações dos sócios. Aduz ter ensino superior completo em administração de empresas, mas nunca exerceu a profissão. Afirmar que Benedito era diretor das empresas, mas não sabe as atividades que exercia (mídia fls. 509).

O réu Benedito Adalberto de Godoy, em juízo confessou os fatos e alegou que a empresa sempre foi familiar e sempre esteve em dia com as contas, entretanto a partir de 2012 perdeu a gerência e foi feita uma "profissionalização" da empresa, ideia trazida por seu diretor-geral, fazendo com que a empresa tivesse uma movimentação nacional. Afirmar que passou e passava por problemas psiquiátricos. Contou que investiu todo o dinheiro que tinha e que os diretores da empresa não aceitavam sua opinião e nem lhe contavam a verdade em razão de não ter estudos. Alega que precisou fechar a empresa de Santa Maria da Serra e a transportadora, bem como rescindiu o contrato de trabalho de mais de 600 funcionários. Alega que a "profissionalização" implicou em licenciamento de marcas e a produção por preço alto, porém com venda por valor baixo. Aduz que venda do produto era por preço muito baixo e por isso não tinha dinheiro para pagar o imposto. Afirmou que precisou pedir recuperação judicial, pois os diretores haviam deixado muitas dívidas, sem nenhum capital de giro. Alega que tentou o parcelamento dos impostos, porém não obteve sucesso. Esclareceu que ficou sabendo sobre os impostos não pagos apenas no ano de 2016. Acrescenta que comprometeu todo seu patrimônio pessoal para pagamento dos débitos da empresa (mídia fls. 509).

Em juízo a ré Ana Clélia de Godoy alegou que não tem conhecimento sobre os fatos, pois sempre trabalhou apenas no setor de recursos humanos. Esclareceu que até o ano de 2011 o réu Adalberto cuidou da empresa e que em 2015 foi incluída pelo diretor geral ao quadro societário, pois a empresa estava enfrentando uma crise financeira. Afirmou que nunca teve acesso ao recolhimento de impostos, dívidas ou dinheiro (mídia fls. 509).

Eis a prova oral constante nos autos.

A acusação lançada na denúncia refere-se à prática de fraude à administração tributária, decorrente do não recolhimento, no prazo legal, de valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (art. 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.137/90).

Portanto, o núcleo típico da conduta reprimida pelo estatuto legal acima mencionado é deixar o sujeito passivo de recolher o tributo, isto é, o dolo do agente é no sentido de que, diante do fato gerador do tributo, deliberadamente deixa de recolher o tributo ainda que o tenha declarado de forma correta ao fisco.

Na hipótese dos autos, diante do contexto probatório é forçoso concluir que o réu Benedito praticou os fatos descritos na denúncia, restando isolada a tese defensiva, pois as testemunhas e os atos constitutivos confirmaram a relação do acusado com a sociedade empresária GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, bem como que de forma dolosa e frequente deixou de recolher o tributo apesar de o cobrar no momento da venda.

Tudo porque, por si, como administradores ou sócios, no período de janeiro, fevereiro, março, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014 e de janeiro, fevereiro e março de 2015 e, ainda, no mês de junho de 2015, na qualidade de

substituto tributário, com o dever de recolher aos cofres públicos o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no prazo legal, não o fez, sonegando assim a quantia de R\$ 2.054.794,48.

Com efeito, da documentação de fls. 7/89 e do interrogatório do réu Benedito, nota-se que a empresa, por sua deliberação, cobrava o tributo ICMS de suas vendas e realizava a declaração fiscal, porém ao invés de destinar ao pagamento do tributo a retinha e desviava para pagamento de outros débitos da empresa que passava por crise financeira.

Ou seja, a acusação acerca de tal conduta é centrada na indicação, em documento fiscal de apuração (GIA's), bem como em certidões de dívida ativa, com notificações prévias do Ministério Público referentes ao inadimplemento dos recolhimentos, cerne da fraude, aproveitados pelos acionados para apuração do efetivo imposto devido mês a mês.

Desta feita, a crise financeira não é justificativa para afastamento do dolo em pagar o ICMS, porquanto o tributo era cobrado das vendas, mas destinado como crédito à empresa em vias de paralisação ao invés de ser destinado ao cumprimento da obrigação tributária para o qual foi cobrado.

A propósito, a prova documental acostada a fls. 07/34, objeto de apuração fiscal, que denota a materialidade delitiva.

Denota-se, assim, a fraude à fiscalização tributária, com a sonegação do ICMS praticado pelo réu Benedito, observado através de documento fiscal (GIA's) e certidões de dívida ativa.

A qualidade de sócios pelos acusados está evidenciada pelo Cadastro de Contribuintes de ICMS (fls. 08)) e ficha cadastral (fls. 72).

Para fins jurídicos, pouco importa que - na prática - o réu Benedito tenha se descuidado da administração da empresa e delegado suas responsabilidades a terceiros. Pode até fazê-lo, mas não deixa de ser responsável pelos atos praticados por seus prepostos ou subordinados. O que o réu propõe, em verdade, é em tese um amplo escudo para a realização dos mais diversos tipos de crimes ou fraudes. Isto porque, como dito acima, ao cobrar o tributo em suas vendas o acusado tinha o valor pago pela mercadoria posta em circulação, logo, ao optar por se valer do dinheiro pago para outros fins ao invés de o destinar ao pagamento do fisco o requerido dolosamente optou por deixar de recolher o tributo na qualidade de sujeito passivo, não por não possuir numerário suficiente para pagamento, mas porque tinha o dolo específico de fraudar o fisco, logo, incorreu na figura típica do artigo 2º, II, da Lei n. 8.137/90, posto que a conduta supera a mera inadimplência, já que demonstrado nos autos que reteve o dinheiro já cobrado a título de ICMS. Neste sentido:

Apelação. Art. 2º, II, da Lei 8.137/90. Preliminar. Alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não ocorrência. Magistrado que não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, desde que do conjunto da decisão se possa extrair o posicionamento adotado pelo julgado. Preliminar rejeitada. Alegada inconstitucionalidade do tipo penal. Suposta prisão por dívida. Não ocorrência. Verdadeira apropriação indébita. Precedente do STJ. Alegada ausência de dolo.

Simples alegação de dificuldade financeira que não afasta a relevância penal da conduta. A prova do alegado compete a quem o fizer. Condenação mantida. Penas.

Redução necessidade. Afastamento da reincidência. Trânsito em julgado posterior aos fatos. Correção de erro material na sentença. Apelo parcialmente provido (TJ-SP. Ap n. 1039567-05.2016.8.26.0602. Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci. J. 30.10.2018).

Ademais, como demonstrado nos autos e confessado pelo réu Benedito, este era responsável pela administração e gerência da empresa, bem como pelo pagamento dos tributos, pois era sócio da empresa e, apesar de alegar que agiu sem dolo, sua versão restou isolada nos autos.

Neste quadro de provas, então, e sempre respeitado entendimento contrário, bem se vê que o acusado Benedito praticou a fraude que ensejou o não recolhimento do imposto devido, causando prejuízo ao erário, tendo o acusado amplos poderes de gestão.

Não é crível, portanto, que tamanho descompasso seja obra do acaso, de terceiro, e o réu Benedito não tenha qualquer participação ou ciência de que os valores

vultuosos informados nos autos foram deixados sem pagamento ao fisco. Não há como se inferir que não tinha consciência da fraude, dada a reiteração delitiva (11 vezes), sendo gestor da empresa.

Confira-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE DEZESSEIS CRIMES, CONSIDERANDO A PENA CONCRETA. ATOS REMANESCENTES. SONEGAÇÃO FISCAL. AGENTE QUE, NA QUALIDADE DE GERENTE ADMINISTRADOR (CONTRIBUINTE DE DIREITO), DEIXA DE RECOLHER AOS COFRES PÚBLICOS, NO PRAZO LEGAL, TRIBUTOS (ICMS) COBRADO E EFETIVAMENTE PAGO PELOS CONTRIBUINTE DE FATO – ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/90. CONDUTA TÍPICA. DOLO CONFIGURADO. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL IMPUGNADO. 1 'O contribuinte efetivamente repassou ao adquirente da mercadoria tributada o ônus representado pelo ICMS. Cobrou-se, portanto, a terceiro, devendo recolher aos cofres públicos o montante assim apurado. Se não o faz, comete crime examinado' (Pedro Roberto Decomain). 2 'Basta, para configurar o dolo inerente ao crime capitulado no art. 2º, II da Lei n. 8.137/90, a vontade livre e consciente de não recolher, aos cofres públicos, o produto dos valores descontados (...)' (STF, Habeas Corpus n. 76.044, do Rio Grande do Sul. Rel. Min. Octavio Galotti). 3 Não há barreira de inconstitucionalidade que afronte as normas incriminadoras dispostas na Lei n. 8.137/90” (SÃO PAULO. Supremo Tribunal Federal. Apelação Criminal nº 2013.013981-3. Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, 2013). Ainda de nosso Tribunal de Justiça:

Pesem as razões dos recursos, na verdade, nesses casos, para apuração da autoria, como já referido, não exige a Lei Especial que o delito seja material praticado pelo punho do réu, sendo suficiente para a imputação de autoria do empresário que ele seja gerente de fato e de direito da empresa comercial e beneficiário direto da redução fiscal, posto tratar-se de crime societário, onde impossível o detalhamento da participação criminosa (Apelação Criminal nº 238.047-3/6-00, rel. Des. Marcos Zanuzzi).

Portanto, assim obrou, verdadeiramente, com dolo e plena consciência, de forma a fraudar a atividade arrecadatória do Estado, por meio do imposto devido na espécie (ICMS), a tanto, sonegando o valor do imposto que deveria recolher aos cofres públicos.

Visto, então, que por largo espaço de tempo, o acusado Benedito fraudou a fiscalização tributária, agindo da mesma forma, em conexão modal, espacial e temporal, assim, realizando conduta criminosa encerrada no comando do disposto no art. 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.137/90, na forma do art. 71, caput, do Código Penal.

Verificadas a materialidade e autoria delitiva, resta somente a mensuração da pena adequada na espécie.

Deste modo, comprovado que o réu Benedito deixou de recolher ICMS, com a finalidade de sonegar tributo, de rigor a condenação.

Noutro giro, no que tange às rés Regina e Clélia, a absolvição é medida que se impõe em vista de que não há dos autos qualquer indício de que foram coniventes com a sonegação praticada pelo acusado Benedito.

E de fato, não há documentação idônea que aponte ciência da sonegação fiscal e a prova oral produzida é unânime em apontar que a acusada Regina não tinha qualquer participação na administração da empresa, apesar da participação societária. No mesmo sentido quanto à acusada Clélia, pois apesar de atuar de forma mais ativa na empresa, nota-se que exercia suas funções de direção somente no departamento de recursos humanos.

Portanto, não há nos autos prova que indique que as acusadas agiram com unidade de desígnios com o acusado a fim de deixar de recolher o tributo sonegado.

Assim, se as únicas provas produzidas em juízo não são capazes de comprovar o dolo das rés, não se pode falar em prova suficiente para a condenação. Fato é que, nestes autos, o Ministério Público não se desincumbiu de provar os fatos imputados na inicial quanto às acusadas. Nesse cenário, incidente o axioma do in dubio pro reo que, justo ou não, o juízo está obrigado a seguir.

Por fim, resta fixar que restou bem demonstrada nos autos a causa de aumento de pena do artigo 12, I, da Lei n. 8.137/90, posto que além vultuoso valor sonegado, a

prova oral demonstrou nos autos que o desfalque tributário causou transtornos ao Município de Santa Maria da Serra, pois se trata de cidade com reduzida população e que dependia dos tributos recolhidos, já que ante ao seu porte pequeno a vultuosa receita sonegada representa boa parte do erário público.

Passa-se à individualização da pena do réu Benedito Adalberto de Godoy, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, e as consequências do crime são desfavoráveis, pois expressivo o crédito tributário no importe de R\$ 2.054.794,48. O acusado não apresenta maus antecedentes. Logo, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1 anos de detenção, com 15 dias-multa.

Em segunda fase, inexistem agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da confissão na forma do artigo 65, III, d, do Código Penal em vista do novo entendimento do E. STJ no REsp n. 1.972.098/SC. Assim, reduz-se a pena em 1/6 para a fixar em 10 meses de detenção com 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena para sopesar. Por outro lado, presente a causa de aumento de pena disposta no artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90 (ocasionar grave dano à coletividade), majorando a pena de metade (por tratar-se de crime praticado por 11 vezes, com alto prejuízo econômico ao erário), tornando-a definitiva em 1 ano e 3 meses de detenção, com 18 dias-multa.

Considerando a continuidade delitiva reconhecida no período entre janeiro de 2014 e junho de 2015, entendo de rigor a majoração da pena em 2/3, porquanto 11 as reiterações delitivas, tornando-a definitiva em 2 anos e 1 mês de detenção, com 30 dias-multa, nos termos do artigo 71 e artigo 72, ambos do Código Penal.

Conforme consta dos autos o acusado é empresário sócio de empresa que, apesar de se encontrar em Recuperação Judicial, realiza movimentação financeira da ordem de milhões de reais, conforme depoimento das testemunhas, bem como o próprio acusado declarou em seu interrogatório renda considerável. Assim, fixo o valor do dia multa em 1 salário mínimo vigente à época dos fatos (CP, art. 49), que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto.

Faz jus o réu à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena, de forma a ser deliberada em sede de execução, e no pagamento de prestação pecuniária no importe de 100 salários-mínimos, considerando as condições econômicas do réu e a vantagem auferida..

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

A) CONDENAR o réu BENEDITO ADALBERTO DE GODOY, qualificado anteriormente nos autos, à pena de 2 anos e 1 mês de detenção, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito nos termos da fundamentação supra, bem como a 30 dias-multa, no valor unitário de 1 salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso (por 11 vezes) no artigo 2º, II, c.c. o artigo 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/90, c.c. o artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal; e

B) ABSOLVER as rés ANA CLELIA DE GODOY e REGINA MARCIA BAPTISTELLA DE GODOY, qualificadas anteriormente nos autos, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não estão presentes os pressupostos fáticos de cabimento da prisão preventiva, podendo o réu recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de dez dias, nos termos do art. 50, caput, do Código Penal; (c) oficie-se o TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF; e (d) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Condene os réus, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código

de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas às NSCGJ/SP.

Sentença com registro eletrônico.

P. I. C.

São Pedro, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA